



Roj: **SAN 5408/2017 - ECLI:ES:AN:2017:5408**

Id Cendoj: **28079230032017100672**

Órgano: **Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **21/12/2017**

Nº de Recurso: **755/2016**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **ANA MARIA SANGÜESA CABEZUDO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAN 5408/2017,**
AAAN 39/2018

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN TERCERA

Núm. de Recurso: 0000755 / 2016

Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General: 04828/20176

Demandante: D^{ña}. Caridad

Procurador: D. ANDRÉS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Letrado: D. ALEJANDRO PEÑA PÉREZ

Demandado: MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogado Del Estado

Ponente Ilma. Sra.: D^a. ANA MARÍA SANGÜESA CABEZUDO

SENTENCIA N°:

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JOSÉ FÉLIX MÉNDEZ CANSECO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO DIAZ FRAILE

D^a. ISABEL GARCÍA GARCÍA BLANCO

D^a. LUCÍA ACÍN AGUADO

D^a. ANA MARÍA SANGÜESA CABEZUDO

Madrid, a veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el presente Recurso tramitado con el **número 755/2016**, seguido a instancia de **DOÑA Caridad**, representada por el procurador Don Andrés Fernández Rodríguez y defendida por el letrado Don Alejandro Peña Pérez, contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado de 21 de mayo de 2016, dictada por delegación

del Ministro de Justicia, siendo demandada la Administración del Estado, representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado.

AN TECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Co n fecha 14 de septiembre de 2016 fue presentado escrito por Doña Caridad , interponiendo recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Director General de los Registros y Notariado de 21 de mayo de 2016, dictada por delegación del Ministro de Justicia, por la que se desestimó el recurso de reposición promovido contra la Resolución de 20 de enero de 2014 por la que se le denegaba la petición de nacionalidad española que habían solicitado por falta de cumplimiento del requisito de residencia legal y continuada establecido en el artículo 22.1 del Código Civil .

SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso y tras la remisión del expediente, se presentó escrito de demanda en el que tras alegar los hechos y fundamentos que estimó de aplicación terminó suplicando que se estimara el recurso y previos los trámites legales se declare su derecho a obtener la nacionalidad española por residencia, con condena en costas a la Administración.

Exponía en la demanda que la resolución impugnada le denegó la nacionalidad española a la solicitante, nacional de Perú, haciendo constar " *Que la interesada no ha justificado el requisito de residencia legalmente exigido porque el 20/10/2011, fecha de la solicitud de nacionalidad, el periodo de residencia legal y efectiva en España no se ha cumplido con continuidad en el tiempo inmediatamente anterior a la petición conforme exige el artículo 22.3 del CC . En la documentación que consta en el expediente no aparece justificada su residencia habitual en territorio español ya que, según informe del Ministerio del interior u otros justificantes solicitados, la interesada tiene ausencias continuadas de España de más de tres meses, concretamente sale de España el 27/10/2010 y entra el 10/03/2011 (cfr. Sentencias de la Audiencia Nacional de 17 de febrero y 12 de diciembre de 2011)* .

En la resolución del recurso de reposición se expresa que la interesada ha tenido unas ausencias del país desde el 31/05/2009 al 28/10/2010 y del 09/03/2011 al 31/11/2012 sin ningún tipo de justificación; de forma errónea, porque se ha tenido en cuenta el certificado de movimientos migratorios expedido en Perú, por lo que las ausencias a considerar son de menor entidad (134 días).

La demandante considera que se ha vulnerado la legislación vigente (artículo 22 del Código Civil) toda vez que entiende que las ausencias no suponen una interrupción en el carácter continuado de la residencia, conforme a la jurisprudencia de la Sala. En efecto, tales ausencias encuentran justificación en la enfermedad del hijo de 4 años de edad de la demandante, que reside en Perú (y así documenta en el expediente una intervención médica del menor el 15 de noviembre de 2010, coincidiendo con el desplazamiento); De otro lado, puede justificar que tiene su domicilio habitual en España, ya que reside legalmente desde 2007; tiene un domicilio estable; comportamiento ejemplar; arraigo familiar (hija menor Serafina nacida en 2011, en 2013 ha reagrupado a sus hijos menores residentes en Perú); cuenta con arraigo laboral de 10 años y trabajo indefinido; De ahí que las salidas del país deban considerarse meramente circunstanciales.

TERCERO.- Dado traslado de la demanda, la Abogacía del Estado presentó escrito en el que se opuso a la demanda en mérito a los hechos y fundamentos que estimó de aplicación al caso, y terminó suplicando que se dictara sentencia de conformidad a derecho. Así opone que la residencia legal ha de ser continuada, lo que es sinónimo de no interrumpida, circunstancia que no se produce en este supuesto. La nacionalidad se solicitó el 20 de octubre de 2011, siendo exigible el plazo de dos años. En el expediente consta certificado de movimientos migratorios en el que se pone de manifestó que la demandante ha tenido ausencias continuadas de entre 3 y 6 meses; así, está fuera de España desde el 28 de octubre de 2010 y el 9 de marzo de 2011. No aparece justificada la residencia habitual y continuada en el territorio, ponderando las ausencias del territorio en relación al tiempo total exigido para adquirir la nacionalidad.

CUARTO.- La cuantía del recurso se fijó en indeterminada y cumplimentados los trámites, quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, el cual quedó fijado para el día 19 de diciembre de 2017.

FU NDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el

suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

La Administración ha denegado al recurrente la concesión de la nacionalidad española al considerar que la residencia legal en España durante más de dos años no ha sido efectiva, circunstancia que es discutida en la demanda. El artículo 22-3 del Código Civil, establece la residencia debe ser "legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición".

Pues bien, el cumplimiento de tal requisito objetivo exige la concurrencia de las tres circunstancias de: a) legalidad de la residencia, lo que supone la sujeción a las normas sobre extranjería que vengan establecidas; b) continuidad o no interrupción del plazo; y c) que tal periodo de residencia corresponda al momento inmediatamente anterior a la solicitud.

La doctrina de la Sala del TS (por todas S. TS Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, de 15 julio 2002, Recurso de Casación núm. 4290/1998) es clara: residencia legal continuada e inmediatamente anterior a la petición no quiere decir prohibición absoluta de salir del territorio nacional durante ese periodo, de modo que (S. TS Sala 3 Secc 6 23-11-2000) la no presencia física ocasional y por razones justificadas del territorio español no presupone el incumplimiento del requisito de residencia continuada siempre que no se traslade la residencia habitual y por ende el domicilio fuera del territorio español. La última de las sentencias citadas hace hincapié en que no se puede confundir el concepto de residencia, entendido éste en sentido técnico jurídico de residencia determinante del domicilio y que por tanto debe ser entendida como residencia habitual, con el de presencia física.

Por otro lado está la exigencia de efectividad en la residencia legal requiere considerar que puede darse el caso en que el solicitante aunque tenga residencia legal no tiene residencia efectiva. La sentencia de 8 de enero de 2004 (TS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 08-11-2004, Rec. 6717/2000) señala que: "B. En esencia, lo que argumenta la parte recurrente en ese primer motivo es que el Código civil no incluye el requisito de efectividad entre los que exige para adquirir la nacionalidad por residencia y ello porque está incluido en el de la residencia legal, constando acreditado en las actuaciones que la reclamante ha residido legalmente -esto es: con la correspondiente autorización administrativa- durante más de diez años en España, hallándose plenamente integrada a las costumbre y estilo de vida español, todo lo cual se encuentra plenamente acreditado en las actuaciones. (...)

"Si bien es cierto, como ya se ha dicho en el Fundamento Primero, que el requisito de la continuidad en la residencia o presencia física no deja de considerarse existente por el hecho de que el interesado haya tenido que realizar, durante el período de tiempo contemplado, cortos y esporádicos viajes o salidas al extranjero, tal permisión, a falta de fijación «ex lege» de un límite a la duración y frecuencia de los mismos, no puede por menos de merecer una interpretación y aplicación restrictiva, que ha de ser ponderada bajo las perspectivas de la accidentalidad o no frecuencia en su realización, de la brevedad en su duración y de la justificación en sus motivos, pues mantener un criterio amplio y permisivo en esta materia, además de ser contrario a la "ratio legis" del precepto regulador de esta forma de adquisición de la nacionalidad, que, como prueba del ánimo del interesado de integrarse en la comunidad española, exige expresamente que su residencia sea continuada, lo que es sinónimo de no interrumpida, podría suponer la apertura de un peligroso y siempre recusable portillo al fraude de ley".

Así esta Sala viene entendiendo que la efectividad y continuidad de la residencia deriva de la fijación real de domicilio en España y la vinculación al territorio en cuanto al medio de vida, desarrollo de las relaciones personales, familiares, sociales, administrativas y demás que conforman el régimen de vida del interesado, que no se desvirtúan por el hecho de que, sin desvincularse de tal relación con el territorio, haya de permanecer en el extranjero por razones de trabajo o estudios (Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 18 Junio 2014, rec. 1089/2013).

SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa resulta del expediente que la demandante, nacida en Perú, solicitó la nacionalidad española por residencia con fecha 20 de octubre de 2011; De la documentación aportada en el expediente se desprende que dicha señora cuenta con autorización de residencia y trabajo desde el válida hasta el 3 de abril de 2007, habiendo sido renovada sucesivamente hasta obtener la autorización de residencia indefinida con fecha 4 de abril de 2012. Aportó con su petición indicación de contar con cuatro hijos; tarjeta de residencia en vigor, pasaporte, certificado de nacimiento y antecedentes penales; certificado de empadronamiento con alta desde 2007 en Puerto de Santa María; certificado de vida laboral con alta; certificado de nacimiento de la menor Serafina (NUM000 .2011), en el que consta referencia al matrimonio de la solicitante con Aquilino, de nacionalidad española, celebrado en Malacavi (Piura -Perú) el 15-1-2011 (no consta inscrito en el Registro Civil Español para el reconocimiento de sus efectos).



El Ministerio Fiscal emitió informe el 22 de diciembre de 2.011, en el que expresa que *"Que a la vista de la documentación aportada, de la que se desprende que la solicitante está con residencia legal y residiendo en España desde el año 2.007, que ha mostrado suficiente arraigo, que tiene una hija menor de edad nacida en España de nacionalidad española, tiene contrato de trabajo y ha cotizado más de 658 días a la Seguridad Social, considera que se han cumplido correctamente todos los requisitos legales e interesa que el Expediente sea elevado para su resolución a la Dirección General de Registros y Notariado, la cual resolverá lo que estime más conveniente"*. El Auto del Encargado de 12 de enero de 2012 se pronuncia en igual sentido.

La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil informó con fecha 30 de octubre de 2012 que la interesada tiene salidas de entre 3 y 6 meses. La Dirección General de Registros y Notariado requirió, por ello, a la interesada para que aportara el certificado de movimientos migratorios al menos del periodo comprendido entre 20/10/2009 y el 20/10/2011, expedido, en su caso, por el Organismo Nacional de su país competente. Y justificación documental de las salidas y entradas, que figuran en el pasaporte del promotor, especialmente las que superan 3/6 meses. La solicitante cumplimentó el requerimiento, adjuntando el certificado, del que resulta los siguientes movimientos desde Perú: 1) Salida el 2 de abril de 2007; 2) Entrada el 4 de diciembre de 2008 y salida el 31 de mayo de 2009; 3) Entrada el 28 de octubre de 2010 y salida el 9 de marzo de 2011; 4) con posterioridad se recogen movimientos de menos de un mes en noviembre de 2002 y abril de 2013.

Además aportó el justificante de intervención médica de su hijo Leon el 11 de noviembre de 2011.

TERCERO.- A la vista de los elementos de hecho obrante en el expediente hemos de examinar si queda probada la residencia legal y continuada, anterior a la petición de nacionalidad, y si existe una voluntad de arraigo manifestada a través de las relaciones familiares y económicas en España, junto a los desplazamientos cuestionados.

No podemos perder de vista que la primera autorización de residencia data de 3 de abril de 2007, y que la petición de nacionalidad es de 20 de octubre de 2011, de modo que se hace uso del plazo abreviado de 2 años que se concede a los nacionales de países iberoamericanos. Quiere decir que en la fecha de la petición la demandante había residido en España 4 años y 6 meses; contando con una experiencia profesional de 658 días. En esa fecha ya contaba con una hija menor de nacionalidad española, y al parecer había contraído matrimonio en el extranjero con un español, pese a que no alude a este hecho ni a la posterior convivencia con aquel.

En ese periodo de estancia, tres de sus hijos siguen residiendo en Perú, y la demandante se desplaza al país en dos ocasiones: entre el 4 de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2009, y entre el 28 de octubre de 2010 y el 9 de marzo de 2011. La primera salida de España durante 6 meses no está justificada, y la segunda viene causalizada por la enfermedad y hospitalización del menor en el mes de noviembre, si bien no consta que la convalecencia se prolongara cuatro meses.

De todo ello, y considerando la fecha de petición de la nacionalidad, entendemos que no se acreditó una residencia continuada, efectiva e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la petición de nacionalidad, puesto que en el periodo de los dos años anteriores existe una salida de más de cuatro meses, que si bien tiene una justificación por razones médicas, evidencia que el centro de intereses personales y familiares sigue estando en el país de origen, como lo muestra el hecho de la estancia en el país de sus hijos, y las estancias de 6 meses y casi 5 meses habidas en el periodo 2008-2011.

Lo que exige el artículo 22 del Código Civil es la presencia y el establecimiento de un centro de intereses personales y económicos en España (Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 15 Octubre 2013, Rec. 100/2012 ; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 13 Junio 2013, Rec. 409/2012); y es precisamente desde esta perspectiva desde la que hemos de examinar las ausencias desplegadas, ya que lo que se observa es una permanencia en España sin ruptura con el país de procedencia. Es posteriormente cuando parece advertirse en las alegaciones de la demandante que hay un establecimiento definitivo en España, pero lo cierto es que en la fecha de la petición de nacionalidad, que es cuando se han de acreditar los requisitos legales, no pudo probarse la residencia legal y continuada en forma.

Las sentencias que cita la demandante en apoyo de su pretensión (Sentencias de 24 y 20 de marzo de 2015 , o 9 de octubre de 2014), inciden en la perspectiva que sostenemos, y por ello acogen la pretensión cuando queda acreditado que las ausencias esporádicas están justificadas y no existe ruptura con España (Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 315/2015 de 24 Marzo 2015, Rec. 248/2013), y a su vez es el centro de relaciones de la interesada en una perspectiva de vinculación como la que implica la nacionalidad (Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 222/2015 de 20 Marzo 2015, Rec. 79/2014 ; o Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 9 Octubre 2014, Rec. 807/2013). Nada de esto sucede en nuestro caso, razón por la que la sentencia debe ser desestimatoria.

CUARTO.- Debe estimarse el recurso, sin mayores consideraciones, y en consecuencia, las costas causadas se imponen a la demandante cuyas pretensiones son íntegramente desestimadas, conforme a la norma general del vencimiento que establece el artículo 139.1 de la LJCA (redacción Ley 37/2011).

FA LLO

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo promovido por DOÑA Caridad , contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado de 21 de mayo de 2016, dictada por delegación del Ministro de Justicia por no ser conforme a derecho.

Las costas causadas se imponen a la demandante.

Atendiendo a la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, la presente es susceptible de *RECURSO DE CASACIÓN* que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de *TREINTA DÍAS* a contar desde el siguiente al de la notificación y que podrá ser admitido a trámite si presenta *interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia* en los términos que se determinan en el art. 88 de la LJCA , *lo que habrá de fundamentarse específicamente , con singular referencia al caso , en el escrito de preparación que, además, deberá cumplir con los requisitos que al efecto marca el art. 89 de la LJCA y cumplir con las especificaciones que al efecto se recogen en el Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE 6-7-2016).*

Con la notificación de la presente se le participa que el TS ha acordado (AUTO 1-3-2017) que, con arreglo a la previsión contenida en el artículo 89.2.c) LJCA , en supuestos de incongruencia omisiva de la sentencia que se pretende combatir, los recurrentes en casación, como presupuesto de procedibilidad, y antes de promover el recurso han de intentar la subsanación de la falta por el trámite de los artículos 267-5 LOPJ y 215-2 LEC . En caso contrario el recurso podrá ser inadmitido en ese concreto motivo.

Al notificarse la presente sentencia se hará la indicación de recursos que previene el art. 248.4 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de junio del Poder Judicial .

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.